

1511087-87.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DISPARIDADES RELEVANTES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL E DOS ATOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511087-87.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511087-87.2020.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vitor José Caldeira

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

VITOR JOSÉ CALDEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal, combinado com os artigos 5º e 7º, ambos da Lei nº 11.340/06, e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, combinado com o artigo 71 do Código Penal (crime continuado), observadas, ainda, as regras do concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), porque, segundo a denúncia:

a) no dia 13 de setembro de 2020, na Rua Quinze de Novembro, nº 1595, apartamento 102, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo por meio do envio de escritos e imagem pelo aplicativo digital de mensagens denominado WhatsApp, em circunstâncias adequadas ao conceito legal de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou sua ex-esposa, Danielle Grillo Alves, de causar-lhe mal injusto e grave;

b) em dia não especificado, no ano de 2020, no período noturno, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, descumpriu decisão judicial que fixara medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 em favor de Danielle Grillo Alves, aproximando-se da residência dela; e

c) entre 13 de novembro de 2019 e 03 de outubro de 2020, em datas e horários diversos, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo de forma continuada, descumpriu decisão judicial que fixara medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 em favor de Danielle Grillo Alves, mediante envio de mensagens e chamadas de vídeo e voz.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu e a vítima foram casados por cinco anos, não têm filhos em comum e estavam separados havia aproximadamente dois anos.

No âmbito do feito nº 1503218-10.2019.8.26.0482, que tramitou na 2ª Vara Criminal desta Comarca, concederam-se em favor de Danielle medidas protetivas de urgência, na forma da Lei nº 11.340/06, para proibir o acusado de se aproximar dela, a distância inferior a 100m (cem metros), e de contatá-la, por qualquer meio de comunicação.

O réu foi pessoalmente cientificado daquela decisão.

No dia 13/09/2020, inconformado com o fim do relacionamento, o denunciado, usando o aplicativo WhatsApp, enviou para a vítima uma imagem eletrônica editada, com a figura de Danielle, no interior do carro dela, e a frase o começo do fim (fls. 31). Com tal ação, causou na ofendida fundado temor.

Com aquela mensagem, além de executar a ameaça, também descumpriu as medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, que o proibiam de contatar Danielle.

Em data não especificada, no ano de 2020, o denunciado estacionou seu automóvel, um GM/Captiva, placas FAW-7831, defronte à residência da vítima, e lá permaneceu, por tempo indeterminado. Com tal ação, aproximou-se da residência de Danielle, a distância inferior a 100m (cem metros).

Em várias outras oportunidades, usando o aplicativo WhatsApp, enviou para Danielle mensagens eletrônicas de conteúdo pretensamente romântico, propondo a retomada do relacionamento afetivo, e realizou chamadas de áudio e vídeo.

Entre 13/11/2019 e 03/10/2020, agindo de forma continuada, usando o aplicativo WhatsApp, enviou para a ofendida mensagens sem conteúdo definido; além de realizar chamadas de áudio e vídeo. Para tanto, usou linhas telefônicas diversas, notadamente as de número 55 18 98159-2439 e 55 18 99649-2617. Com tais ações, reiteradamente descumpriu as medidas protetivas de urgência que o proibiam de contatá-la.

Exemplificativamente, no dia 18/11/2019, usando a linha telefônica nº 55 18 98159-2439, enviou para Danielle uma figura eletrônica do tipo emoji, com um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, além de uma mensagem, posteriormente apagada por ele.

No dia 27/11/2019, usando a linha telefônica nº 55 18 98159-2439, enviou para a vítima uma mensagem eletrônica de texto, com os dizeres Good morning. Are you married.

No dia 17/12/2019, usando a linha telefônica nº 55 18 99649-2617, enviou para Danielle uma mensagem eletrônica posteriormente apagada por ele e efetuou uma chamada de vídeo.

Nos dias 20/02/2020 e 26/03/2020, realizou duas chamadas de voz para a ofendida. A denúncia (fls. 115/118) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/102).

Em audiência realizada no dia 14 de julho de 2021, a vítima ratificou a representação pertinente ao crime de ameaça, a denúncia foi recebida e realizou-se a citação (fls. 147/148).

Assistido por Defensor constituído (fls. 160), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 150/159).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 614).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado (fls. 643/644). As declarações orais foram captadas em gravação audiovisual.

Substituídos os debates por memoriais escritos, o Ministério Público apresentou-os, postulando a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 683/690).

O Defensor, por sua vez, pleiteou a absolvição, alegando a insuficiência da prova

colhida para embasar decisão condenatória (fls. 693/700).

Juntou-se documento (fls. 709), sobre o qual se manifestaram o Ministério Público (fls. 712) e o Defensor (fls. 716/717).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impositivo, assim, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de descumprimento de decisão que estabeleceu medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.340/06) ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), pelos documentos de fls. 12, 30/33, 46/47, 73/94 e 709, e pela prova oral, colhida sob o contraditório.

Não há, contudo, prova suficiente da ocorrência do crime de ameaça.

A prova oral revelou a autoria da infração penal (artigo 24-A da Lei nº 11.340/06). Relatos orais.

A vítima, Danielle Grillo Alves Caldeira (fls. 643/644), declarou que viveu maritalmente com o réu por quatro anos. Afirmou que sofria violência doméstica durante o casamento. Na época em que foram casados, trabalhavam no mesmo imóvel. Após a separação, a depoente saiu de casa e mudou-se para um apartamento, em prédio situado defronte ao imóvel onde está estabelecido seu novo local de trabalho. Após o fim do relacionamento, o acusado passou a persegui-la em lugares públicos, como o templo religioso que frequenta. Também a perseguia em seu novo ambiente de trabalho e em sua casa. Após o deferimento das medidas protetivas, o réu compareceu ao local de trabalho da depoente e disse para as meninas da portaria que poderia ingressar, pois era seu marido. A perseguição nesse ambiente começou em maio de 2019 e perdurou até o início de 2021. Disse que o réu estacionava o carro onde pudesse visualizar o seu apartamento e seu novo local de trabalho. Certa vez, estava atravessando a rua, quando Vitor veio com o automóvel e parou em cima da depoente. Em seguida, ele abriu a janela do veículo e disse-lhe retira a queixa da delegacia, senão a situação vai ficar ruim, não vai dar pra prosseguir com qualquer tipo de acordo. Afirmou que, por mais de cinco vezes, ele estacionou o carro nas imediações de sua casa. Várias vezes ele enviou mensagens eletrônicas, usando números de telefone que não eram o oficialmente usado por ele. Por um tempo, Vitor enviou-lhe mensagens com frequência quase diária. Por meio de algumas daquelas mensagens, ele afirmou que apenas celebraria acordo de divórcio se a depoente retirasse as medidas protetivas. Também por meio de mensagens de WhatsApp, ele a ameaçou. Uma dessas ameaças foi executada mediante envio de uma fotografia da depoente no interior de uma caminhonete e a legenda o começo do fim. Em outra ocasião, Vitor enviou-lhe música da série de ficção You, em que o protagonista mata o par romântico. Afirmou que é sócia do acusado em uma empresa e as notas fiscais são emitidas por secretárias. Declarou que as capturas de tela, prints, das mensagens foram entregues à Autoridade Policial. Salientou que as mensagens apresentadas no processo anterior eram diferentes das que ensejaram este feito. Como aquele processo já estava em andamento, foi informada de que as mensagens não entravam mais naquele caso. Asseverou que o acusado, desde o princípio, no processo anterior e neste, usava vários números de telefones.

A testemunha Vilma André Grillo Silva (fls. 643/644), tia da vítima, disse que não presenciou os fatos narrados na denúncia. Segundo a mãe de Danielle, irmã da depoente, certa vez, ela foi à residência da vítima e viu o carro do acusado nas imediações. Em outra ocasião, anterior à separação, Danielle estava na casa da depoente, quando o réu telefonou, em chamada de vídeo, e exigiu que ela filmasse a casa, para mostrar onde estava. A depoente considerava o réu bastante ciumento. Disse que nunca presenciou discussão entre eles. Após o divórcio, ele telefonou para a depoente e, a princípio, disse-lhe que desejava visitá-la. Logo depois, ele voltou a telefonar e disse-lhe que não poderia comparecer à sua residência, pois estavam vigentes medidas protetivas que o proibiriam de contatar familiares de Danielle. Por isso, ele pediu que a depoente fosse ao consultório dele, pois assim poderiam dizer que se tratava de uma consulta comum. A depoente disse que atenderia ao pedido dele, mas não o fez.

A testemunha Edmur dos Santos Alves (fls. 643/644), pai da vítima, declarou que o réu enviava mensagens ameaçadoras para sua filha. Danielle costumava reenviar as mensagens para a esposa do depoente. Disse crer que ele enviava mensagens para Danielle com frequência quase diária. Certa vez, o depoente pegou o acusado defronte à residência da filha, no período noturno, sentado junto ao portão. Ressalvou que não viu o carro dele naquela ocasião. O depoente perguntou o que ele estava fazendo ali e Vítor respondeu que estava conhecendo a região. Disse que não sabe informar os números de telefone usados no envio das mensagens.

Regina Grillo Alves (fls. 643/644), mãe da vítima, afirmou que o acusado, após a concessão das medidas protetivas, contatou a vítima por várias vezes. Declarou que direto ele passava em frente à casa dela ou ficava em frente ao imóvel, em um carro preto. Certa vez, Danielle estava no mercado e telefonou para a depoente, dizendo que Vítor a seguira. A depoente e seu esposo foram para a casa dela. Quando chegaram, viram o acusado, num carro preto, nas imediações do imóvel. Diversas vezes, ele enviou mensagens para Danielle, as quais ela costumava printar e enviar para a depoente. Em uma ocasião, ele lhe telefonou (usando a própria linha telefônica), mas a depoente não o atendeu. Em outra oportunidade, Vítor enviou mensagem com uma foto e a legenda o começo do fim, circunstância que os deixou muito preocupados. Considerou que aquela mensagem era uma ameaça, pois inexistia motivo para que ele a enviasse. Disse crer que Vítor fez referência a algum filme. Em outra data, durante a noite, viram o acusado defronte ao prédio onde Danielle reside. Quando Edmur indagou o que ele fazia ali, Vítor disse que não estava fazendo nada e saiu caminhando.

A testemunha Oswaldo Heitor Nallim Júnior (fls. 643/644) disse que conhece o réu desde 1998 e nunca teve notícia do envolvimento dele em brigas ou fatos correlatos. Interrogado (fls. 643/644), o réu negou a prática dos crimes. Disse que tem renda mensal entre doze e treze mil reais. Durante o casamento, comprou um veículo para agradar a Danielle e parcelou o pagamento de parte do preço. Depois de um tempo, sem condições de pagar as parcelas do preço, negociou a entrega do bem à instituição financeira que lhe concedera o crédito. No dia ajustado para a entrega, Danielle escondeu o carro. Por isso, o credor ajuizou pedido de busca e apreensão do veículo. Após esse episódio, separaram-se. Declarou que Danielle estava insatisfeita com a sua condição financeira. Dois meses depois, quando apreenderam a caminhonete, Danielle solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência. Disse que enviou algumas mensagens para a vítima, principalmente antes das medidas protetivas. Asseverou que Danielle o proibiu de usar a pessoa jurídica que constituíram em sociedade. Contudo, ela não pagava os débitos relacionados à empresa. A princípio, enviou algumas mensagens, com o objetivo de reatar o casamento. Após a concessão de medidas protetivas, houve algumas mensagens. Uma vez compareceu às imediações do prédio da vítima, mas anteriormente à concessão de medidas protetivas. Negou que telefonasse para Danielle. Declarou que, certa vez, telefonou para a mãe de Danielle equivocadamente. Disse que enviou a mensagem com a legenda o começo do fim e imagem da caminhonete, por considerar que os fatos envolvendo o veículo foram um ponto crucial do casamento. O fim, naquele contexto, era alusão ao fim do relacionamento.

Artigo 147 do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, o réu ameaçou a ofendida no dia 13/09/2020, por meio do envio de imagem eletrônica com a figura de Danielle, no interior do carro dela, e a frase o começo do fim (fls. 31).

Outros episódios narrados pela vítima, como o envio de música da trilha sonora de série de ficção, não são objeto desta ação penal.

A imagem eletrônica descrita na inicial acusatória está à fl. 31.

É certo que foi enviada pelo réu a Danielle, por meio do aplicativo WhatsApp, pois os relatos de ambos convergiram quanto a esse ponto.

Entretanto, não é possível afirmar, de forma isenta de dúvidas, que o acusado agiu dolosamente.

A configuração do crime de ameaça (art. 147, CP) pressupõe dolo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar alguém (MASSON, Cleber. Código Penal comentado, 2ª ed. ebook, São Paulo: Método, 2014, p. 1108).

No caso, o denunciado asseverou que usou a expressão o começo do fim para se referir à causa do término de seu casamento com a ofendida. Segundo o acusado, um dos motivos da separação foi a incapacidade do casal para adimplir parcelas do financiamento do preço do veículo fotografado, que acarretou a apreensão do bem. Por isso, considerou que a compra da caminhonete foi o começo do fim do relacionamento.

O documento de fls. 178/181 demonstra que o denunciado, em 15/05/2017, contratou crédito bancário com alienação fiduciária de um veículo Toyota/Hilux CD Flex.

O contrato de financiamento confere verossimilhança à versão apresentada pelo réu, no sentido de que ele considera a aquisição do veículo a causa do fim do casamento, isto é, o começo do fim do matrimônio.

A expressão usada pelo réu, aposta sobre aquela fotografia, não constitui, por si só, promessa de mal injusto e grave. Não encerra, em seu próprio conteúdo, a asserção de um mal futuro.

A imagem editada poderia, em tese, configurar ameaça velada, se se concluísse, por exemplo, que se tratava de referência ao fim da vida da destinatária.

Entretanto, o contrato de crédito (fls. 178/181) e a informação contida na denúncia, de que o acusado tentava reatar o relacionamento, indicam que ele, por meio da mensagem eletrônica, pretendia referir-se ao fato que considerava ter motivado a separação. Portanto, não desejava usar a imagem como instrumento de intimidação.

Como a imagem de fls. 31 não encerra em si ameaça explícita e é plausível a adução de que não desejava atemorizar a ofendida, não é seguro afirmar que o denunciado agiu dolosamente.

Por conseguinte, impõe-se a absolvição de Vitor José Caldeira da imputação de prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, combinado com os artigos 5º e 7º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Artigo 24-A da Lei nº 11.340/06. Arguição de ilicitude das capturas de tela, screen prints, de fls. 46/57 e 73/94.

O Defensor afirmou que capturas de tela são provas ilícitas (fls. 695).

Segundo sua argumentação, o Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do HC 133430 – PE e do RHC 99.735/SC, declarou que são ilícitas imagens de conversas de aplicativos, os chamados “print screen” da tela de aplicativos de mensagens (fls. 695).

Os acórdãos indicados tratam expressa e exclusivamente da ferramenta WhatsApp Web, usada para pareamento (espelhamento) entre o aplicativo de mensagens instalado em smartphone e um navegador ou aplicativo instalado em desktop.

Como o Defensor omitiu esta informação, de que os acórdãos invocados tratam exclusivamente de provas colhidas mediante espelhamento com WhatsApp Web, transcrevo integralmente as ementas, com sublinhas nos trechos de interesse:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO COM A CAPTURA DA TELA DAS CONVERSAS DO WHATSAPP. INTERLOCUTOR INTEGRANTE DO GRUPO DE CONVERSAS DO APLICATIVO. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO PODER PÚBLICO. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. NULIDADE VERIFICADA. DEMAIS PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há ilegalidade no inquérito policial, pois, após a notícia anônima do crime, foi adotado um procedimento preliminar para apurar indícios de conduta delitiva, antes de serem adotadas medidas mais drásticas, como a quebra do sigilo telefônico, sendo que as delações anônimas não foram os únicos elementos utilizados para a instauração do procedimento investigatório, conforme a transcrição do Relatório Técnico, datado de 30/12/2015, no acórdão proferido no RHC 79.848. Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE nos autos do RHC 79.848, "No IPL há a denúncia por escrito e assinada com a qualificação dos denunciantes, assim não há que se falar em que somente houve denúncia anônima para a instauração de um IPL" (fl. 736 do RHC 79.848). 2. Consta dos autos que os prints das conversas do WhatsApp teriam sido efetivados por um dos integrantes do grupo de conversas do aplicativo, isto é, seria um dos próprios interlocutores, haja vista que ainda consta no acórdão do Tribunal de origem que,

"como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça que '(...) a tese da defesa de que a prova é ilícita se contrapõe a tese da acusação de que as conversas foram vazadas por um dos próprios interlocutores devendo ser objeto de prova no decorrer da instrução processual'". 3. Esta Sexta Turma entende que é inválida a prova obtida pelo WhatsApp Web, pois "é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários" (precedentes). 4. Agravo regimental parcialmente provido, para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes. (STJ, AgRg no RHC n. 133.430/PE, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/02/2021; DJe 26/02/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DISPARIDADES RELEVANTES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL E DOS ATOS E PROVAS DEPENDENTES. PRESENÇA DE OUTRAS ILEGALIDADES. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PRIVACIDADE DETERMINADA SEM INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FIXAÇÃO DIRETA DE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que, após coleta de dados do aplicativo WhatsApp, realizada pela Autoridade Policial mediante apreensão judicialmente autorizada de celular e subsequente espelhamento das mensagens recebidas e enviadas, os Recorrentes tiveram decretadas contra si prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. 2. O espelhamento das mensagens do WhatsApp ocorre em sítio eletrônico disponibilizado pela própria empresa, denominado WhatsApp Web. Na referida plataforma, é gerado um tipo específico de código de barras, conhecido como Código QR (Quick Response), o qual só pode ser lido pelo celular do usuário que pretende usufruir do serviço. Daí a necessidade de apreensão, ainda que por breve período de tempo, do aparelho telefônico que se pretende monitorar. 3. Para além de permitir o acesso ilimitado a todas as conversas passadas, presentes e futuras, a ferramenta WhatsApp Web foi desenvolvida com o objetivo de possibilitar ao usuário a realização de todos os atos de comunicação a que teria acesso no próprio celular. O emparelhamento entre celular e computador autoriza o usuário, se por algum motivo assim desejar, a conversar dentro do aplicativo do celular e, simultaneamente, no navegador da internet, ocasião em que as conversas são automaticamente atualizadas na plataforma que não esteja sendo utilizada. 4. Tanto no aplicativo, quanto no navegador, é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários. 5. Cumpre assinalar, portanto, que o caso dos autos difere da situação, com legalidade amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em que, a exemplo de

conversas mantidas por e-mail, ocorre autorização judicial para a obtenção, sem espelhamento, de conversas já registradas no aplicativo WhatsApp, com o propósito de periciar seu conteúdo. 6. É impossível, tal como sugerido no acórdão impugnado, proceder a uma analogia entre o instituto da interceptação telefônica (art. 1.º, da Lei n.º 9.296/1996) e a medida que foi tomada no presente caso. 7. Primeiro: ao contrário da interceptação telefônica, no âmbito da qual o investigador de polícia atua como mero observador de conversas empreendidas por terceiros, no espelhamento via WhatsApp Web o investigador de polícia tem a concreta possibilidade de atuar como participante tanto das conversas que vêm a ser realizadas quanto das conversas que já estão registradas no aparelho celular, haja vista ter o poder, conferido pela própria plataforma online, de interagir nos diálogos mediante envio de novas mensagens a qualquer contato presente no celular e exclusão, com total liberdade, e sem deixar vestígios, de qualquer mensagem passada, presente ou, se for o caso, futura. 8. O fato de eventual exclusão de mensagens enviadas (na modalidade "Apagar para mim") ou recebidas (em qualquer caso) não deixar absolutamente nenhum vestígio nem para o usuário nem para o destinatário, e o fato de tais mensagens excluídas, em razão da criptografia end-to-end, não ficarem armazenadas em nenhum servidor, constituem fundamentos suficientes para a conclusão de que a admissão de tal meio de obtenção de prova implicaria indevida presunção absoluta da legitimidade dos atos dos investigadores, dado que exigir contraposição idônea por parte do investigado seria equivalente a demandar-lhe produção de prova diabólica. 9. Segundo: ao contrário da interceptação telefônica, que tem como objeto a escuta de conversas realizadas apenas depois da autorização judicial (ex nunc), o espelhamento via Código QR viabiliza ao investigador de polícia acesso amplo e irrestrito a toda e qualquer comunicação realizada antes da mencionada autorização, operando efeitos retroativos (ex tunc). 10. Terceiro: ao contrário da interceptação telefônica, que é operacionalizada sem a necessidade simultânea de busca pessoal ou domiciliar para apreensão de aparelho telefônico, o espelhamento via Código QR depende da abordagem do indivíduo ou do vasculhamento de sua residência, com apreensão de seu aparelho telefônico por breve período de tempo e posterior devolução desacompanhada de qualquer menção, por parte da Autoridade Policial, à realização da medida constritiva, ou mesmo, porventura - embora não haja nos autos notícia de que isso tenha ocorrido no caso concreto -, acompanhada de afirmação falsa de que nada foi feito. 11. Hipótese concreta dos autos que revela, ainda, outras três ilegalidades: (a) sem que se apontasse nenhum fato novo na decisão, a medida foi autorizada quatro meses após ter sido determinado o arquivamento dos autos; (b) ausência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal a respaldar a limitação do direito de privacidade; e (c) ilegalidade na fixação direta do prazo de 60 (sessenta) dias, com prorrogação por igual período. 12. Recurso provido, a fim de declarar a nulidade da decisão judicial que autorizou o espelhamento do WhatsApp via Código QR, bem como das provas e dos atos que dela diretamente dependam ou sejam consequência, ressalvadas eventuais fontes independentes, revogando, por conseguinte, a prisão preventiva dos Recorrentes, se por outro motivo não estiverem presos. (STJ, RHC n. 99.735/SC, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/11/2018; DJe de 12/12/2018).

O Defensor suprimiu as informações de que os julgados concernem exclusivamente à ferramenta de espelhamento WhatsApp Web; de que um deles (RHC 99.735/SC) versa sobre o espelhamento por investigador de polícia, pessoa alheia à conversa eletrônica; e de que se consignou, no outro (AgRg no RHC n. 133.430/PE), expressa alusão de que a tese de ilicitude se contrapõe a tese da acusação de que as conversas foram vazadas por um dos próprios interlocutores.

Evidentemente, se a tese da ilicitude se contrapõe à alegação de que os prints provêm de interlocutores é porque esse (o vazamento por interlocutores) não enseja ilicitude da prova.

No caso em exame, as conversas foram capturadas por um dos interlocutores, com a finalidade de servirem de prova de que o réu estava a descumprir decisão que estabelecera, em favor da vítima, medidas protetivas de urgência.

Como as conversas foram capturadas Danielle, interlocutora, com a finalidade probatória, não se vislumbra ilicitude. Utiliza-se, mutatis mutandis, o

entendimento aplicável à gravação de telefonemas por um dos interlocutores. Veja-se:

(...) a uníssona jurisprudência desta Corte, em perfeita consonância com a do Pretório Excelso, firmou o entendimento de que a gravação efetuada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, é prova lícita, que pode servir de elemento probatório para a notitia criminis e para a persecução criminal. Ademais, ao contrário do que afirma o Recorrente, na hipótese, trata-se de gravação efetuada por funcionários públicos no exercício de sua função pública, e não de conversa particular ou sigilosa, o que afasta tese de ilegalidade da prova por ofensa à garantia da intimidade da vida privada do Acusado (...). (STJ, AgRg no RHC n. 165.495/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/08/2022; DJe 30/8/2022).

Artigo 24-A da Lei nº 11.340/06. Questionamentos do Defensor sobre a autenticidade dos documentos de fls. 46/57 e 73/94.

O Defensor questionou a autenticidade dos documentos de fls. 46/57 e 73/94, alegando que os arquivos digitais originais não foram periciados (fls. 694) e que as imagens podem ser facilmente adulteradas (fls. 695).

A arguição de falsidade documental pressupõe a outorga de poderes especiais ao Defensor (art. 146, CPP) e é cognoscível por meio de incidente processual específico (art. 145 e seguintes, CPP).

No caso, o Defensor não recebeu poderes especiais e a estratégia de questionar a autenticidade dos documentos contraria as declarações pessoais do acusado, no sentido de que enviou algumas mensagens para a vítima após a concessão de medidas protetivas de urgência.

Tampouco se optou pela arguição direta de falsidade. Ou seja, não se afirmou a inautenticidade dos documentos. Optou-se por, em termos vagos, aventar-se que arquivos digitais são facilmente manipuláveis (fls. 694, último parágrafo) e que imagens digitais podem ser facilmente adulteradas (fls. 695).

Portanto, o Defensor não recebeu poderes especiais para alegar falsidade documental (art. 146, CPP); não alegou a falsidade diretamente; e não elegeu a via adequada (art. 145, CPP). No mais, os questionamentos quanto à autenticidade da prova contrariam as declarações pessoais do réu.

Ante a ausência de poderes especiais e a inadequação da via eleita, as aduções de falsidade documental não devem ser conhecidas.

Ainda que fossem conhecidas, as declarações do réu, no sentido de que enviou mensagens para a vítima após a concessão de medidas protetivas, incluindo aquela com a legenda o começo do fim, bastariam para afastar as aduções de inautenticidade.

Artigo 24-A da Lei nº 11.340/06. Delimitação dos fatos.

Consignou-se, na inicial acusatória, que o descumprimento de decisão que estabeleceu medidas protetivas de urgência se deu mediante permanência do réu defronte à residência da vítima, no automóvel GM/Captiva, placas FAW-7831; reiterado envio de mensagens eletrônicas, por meio do aplicativo WhatsApp; e reiterada realização de chamadas de áudio e vídeo para a ofendida.

Outros episódios descritos pela vítima e pelas testemunhas não são objeto desta ação penal.

Por não serem objeto da ação penal, não serão analisados os relatos de que Vitor telefonou para familiares de Danielle, compareceu ao local de trabalho dela e foi surpreendido diante do edifício onde ela reside, sem o carro.

Artigo 24-A da Lei nº 11.340/06. Análise dos fatos.

O documento de fls. 12 evidencia que o acusado estava sujeito a medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/06, que o proibiam de se aproximar de Danielle Grillo Alves e de contatá-la.

No feito nº 1503218-10.2019.8.26.0482, estabeleceram-se, liminarmente, medidas protetivas consistentes em proibição de aproximação de Danielle, em distância inferior a 100m (cem metros), e proibição de contato com ela (fls. 12)

O documento de fls. 709 demonstra que o réu estava ciente das proibições, pois recebeu intimação no dia 28/06/2019.

Conforme se expôs anteriormente, o acusado, no interrogatório (fls. 643/644), negou



que telefonasse para Danielle. Disse que enviou algumas mensagens para ela após a concessão de medidas protetivas de urgência. Declarou que seu comparecimento às imediações do prédio onde sua ex-esposa reside foi anterior à concessão de medidas protetivas. Declarou que enviou a mensagem com a legenda o começo do fim. Segundo Danielle Grillo Alves (fls. 643/644), o acusado, várias vezes, estacionou o carro nas imediações de sua residência. Além disso, durante certo período, com frequência quase diária, usando linhas telefônicas que não eram oficialmente utilizadas por ele, enviou-lhe mensagens eletrônicas, por meio do aplicativo WhatsApp. Por meio daquelas mensagens, ora pedia a retirada das medidas protetivas, ora a ameaçava. Dentre as mensagens, enviou-lhe a imagem com a legenda o começo do fim. Afirmou que os prints das mensagens foram entregues à Autoridade Policial. O Defensor alegou que titularidade das linhas telefônicas não restou comprovada (fls. 695). Questionou, ainda, as circunstâncias de produção das fotografias do veículo do acusado, afirmando que podem ter sido capturadas por qualquer pessoa, em qualquer lugar (fls. 695).

Conforme se expôs anteriormente, o réu informou que enviou imagem eletrônica com fotografia de Danielle no interior de uma caminhonete e a sobreposição da legenda o começo do fim.

A imagem referida pelo acusado está às fls. 31 e o usuário de WhatsApp remetente está identificado como Vitor 2.

Conquanto o Defensor tenha questionado a titularidade das linhas telefônicas usadas no envio de mensagens, o documento de fls. 31 e as declarações do denunciado demonstram que ele era o usuário identificado como Vitor 2.

Usando o aplicativo Whatsapp (Vitor 2), o denunciado enviou dezenas de mensagens eletrônicas para a ofendida, em datas variadas.

Por meio das capturas de tela de fls. 73/86, constata-se que o acusado (usuário Vitor 2) enviou mensagens para Danielle nos dias 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 de agosto de 2019, sendo apagada a mensagem do dia 31 (fls. 73/77 e 84); 01, 03, 04, 05, 07, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2019, sendo que foram apagadas as mensagens dos dias 01, 03, 04 e 26 (fls. 77/81); 03 de outubro de 2020, apagada (fls. 81); 10, 11, 14 e 17 de dezembro de 2019, todas apagadas (fls. 81); e 28 e 29 de abril de 2020, sendo que foi apagada a mensagem do dia 28 (fls. 81). Deixo de usar as tentativas de telefonema por meio do aplicativo WhatsApp como evidências de consumação do delito porque, segundo os documentos de fls. 73/86, nenhuma das ligações foi atendida. Portanto, não se consumou a comunicação entre o réu e Danielle, por meio de telefonemas e chamadas de vídeo.

Impossível saber se a ausência de comunicação por telefonemas e chamadas de vídeo decorreu de recusa de Danielle em atendê-lo ou desistência do acusado. Por não ser possível inferir se a ausência de comunicação por meio de telefonemas e chamadas de vídeo decorreu de fator estranho aos desígnios do agente (recusa de Danielle) ou da vontade dele (desistência voluntária), não se aplica a previsão contida no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Ao enviar mensagens eletrônicas (fls. 73/86), o denunciado reiteradamente violou a proibição de contatar Danielle (fls. 12).

Como descumpriu a decisão judicial que fixara medida protetiva de urgência consistente em proibição de contatar Danielle Grillo Alves (fls. 12), o acusado reiteradamente praticou o crime previsto no caput do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

As declarações de Danielle evidenciam que Vítor, depois de cientificado da ordem de afastamento, estacionou o automóvel defronte ao edifício onde sua ex-esposa residia e lá permaneceu.

Não há sequer indício de que a vítima tenha narrado fato anterior à fixação de medidas protetivas de urgência e as fotografias de fls. 31/33 coonestam seu relato. As fotografias (fls. 31/33) foram capturadas de nível superior ao da via pública, de cima para baixo. O ângulo de captura das imagens coincide com a narrativa de Danielle, no sentido de que o réu estacionava em lugar a partir de onde enxergava o apartamento da ex-esposa.

Portanto, as declarações de Danielle evidenciam que o réu, ciente da ordem judicial que o proibia de se aproximar dela, a distância inferior a 100m (cem metros),

estacionou o automóvel e permaneceu defronte à moradia de sua ex-esposa. Com essa ação, o denunciado violou a decisão judicial e praticou a conduta abstratamente prevista no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Concurso de crimes.

Para delimitar o número de reiteraões do crime, consigno que o réu enviou mensagens para Danielle em, ao menos, 29 (vinte e nove) dias distintos, ou seja, nos dias 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 de agosto de 2019 (fls. 73/77 e 84); 01, 03, 04, 05, 07, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2019 (fls. 77/81); 03 de outubro de 2020 (fls. 81); 10, 11, 14 e 17 de dezembro de 2019 (fls. 81); e 28 e 29 de abril de 2020 (fls. 81).

Além das mensagens, em data não determinada, após a fixação de medidas protetivas de urgência, aproximou-se de Danielle, ao menos, uma vez, em distância inferior a 100m (cem metros).

Portanto, o acusado consumou o crime (art. 24-A, Lei nº 11.340/06) por 30 (trinta) vezes.

Como as infrações penais foram praticadas contra a mesma vítima, em breve intervalo temporal, na mesma cidade e com método de execução similar, as subseqüentes devem ser reputadas continuação da primeira, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Demonstradas a materialidade delitiva e a autoria e ausentes excludentes da ilicitude e dirimentes da culpabilidade, impõe-se a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, por 30 (trinta) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal).

Passo a dosar a pena.

Dosimetria.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico a ausência de circunstâncias negativas ou positivas a serem ponderadas na primeira fase da dosimetria.

Por conseguinte, fixa-se a sanção no nível mínimo, ou seja, 03 (três) meses de detenção, para cada crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu confessou parte dos delitos, dizendo que enviou algumas mensagens após a fixação de medidas protetivas de urgência (art. 65, III, d, CP). Entrementes, é incabível a atenuação das sanções para nível inferior ao mínimo, nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ).

Logo, permanecem as penas nos níveis iniciais.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena específicas a serem consideradas.

Configurada a relação de continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) entre 30 (trinta) crimes apenados com sanções idênticas, aplica-se somente uma das reprimendas, majorada de 2/3 (dois terços). Por conseguinte, passam-se as reprimendas para 05 (cinco) meses de detenção.

A pena será cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, CP).

Inviável a substituição da sanção corporal por multa, em face da vedação contida no artigo 17 da Lei nº 11.340/06.

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), consistente em limitação de fim de semana. Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar VITOR JOSÉ CALDEIRA, filho de Alzira Caldeira e de Mário Antonio da Purificação Caldeira, nascido aos 25/01/1959, natural de Presidente Prudente/SP, inscrito no RG sob o nº 9.809.444-0 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, por 30 (trinta) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicialmente aberto; e para absolvê-lo da imputação de prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, combinado com os artigos 5º e 7º, ambos da Lei nº 11.340/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), consistente em limitação de fim de semana. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Por falta de elementos, deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP).

Cientifique-se a vítima (art. 399, NSCGJ).

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 160).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento das custas processuais, e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se estes autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA